

1500109-12.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da droga. Não descaracteriza o delito de tráfico de substância entorpecente o fato de a Polícia haver apreendido pequena quantidade do tóxico em poder do réu" (STF 1ª T. HC n. 74.420-6/RJ Rel. Min. Celso de Mello DJU de 19.12.96, p. 51.768).

Portanto, o acusado realizou conduta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500109-12.2022.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500109-12.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2011043/2022 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 22413296 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 55/22/138 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2011043 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO NICOLAS DE SOUZA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

ROBERTO NICOLAS DE SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no 12 de janeiro de 2022, por volta das 13h30, na Reginalda Campodônio Dias, nº 75, bairro Assunção, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, guardava drogas consistentes em 2,0g de Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como maconha, acondicionados em 01 invólucro plástico; e 19,0g de cocaína, acondicionadas em 50 eppendorfs, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, na data e local acima indicados, o acusado guardava cinquenta e uma embalagens individuais de drogas para fins de tráfico.

Consta dos autos que policiais civis receberam a informação de que na Rua Reginalda Campodônio Dias, Bairro Assunção, nesta Comarca de São Bernardo do Campo, indivíduos traficavam entorpecentes em plena via pública, razão pela qual para lá se dirigiram.

Assim que ingressaram na via, os policiais avistaram o acusado na posse de uma pequena bolsa, parado na calçada, razão pela qual deliberaram pela abordagem.

Realizadas buscas no interior da referida bolsa, os policiais encontraram 50 eppendorfs contendo cocaína e 01 embalagem com maconha, além da quantia de R\$ 14,00 (quatorze reais) em espécie.

Indagado, o acusado confessou que as drogas localizadas em sua posse se destinavam à mercancia espúria e que o numerário era proveniente da venda dos entorpecentes, alegando, ainda, estar "chapadão" e "doido de droga".

Nestas circunstâncias, ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.

A quantidade das drogas apreendidas, a sua forma de acondicionamento, a apreensão de dinheiro, bem como as circunstâncias nas quais se deu a prisão em flagrante revelam a prática do tráfico de entorpecentes.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial a págs. 04/30. Notificado a pág.83, o acusado ofertou defesa preliminar a pág.87. Recebida a denúncia às págs.88/89, o réu foi citado a pág.107). Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, interrogando-se o réu.

Em debates, o Ministério Público requer a condenação do réu nos termos da denúncia e fixação de regime inicial fechado, reconhecida a reincidência.

A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO:

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares do delito de tráfico de substância entorpecente praticado pelo acusado, inexistindo dúvida quanto à autoria.

A materialidade delitiva está demonstrada no auto de exibição e apreensão a pág.16/17 (dinheiro, bolsa e droga); nos laudos de constatação (págs.23/25), químico-toxicológico (págs.79/81) e pericial às págs.121/122 (bolsa), bem como no comprovante de depósito juntado a pág.43.

Quanto à autoria, após a opção pelo silêncio na fase policial (pág.08/09), em Juízo o acusado negou a prática do delito:

A Rua Reginalda Campodônio Dias, onde foi abordado, é local de sua residência. Não portava pochete contendo a quantidade de droga indicada na denúncia. Trazia no

bolso uma porção de maconha e quinze porções de cocaína, ambas para o próprio consumo, pelas quais pagou a quantia total de R\$160,00. É usuário de droga. Não trazia quantia em dinheiro.

Os policiais civis já tinham efetuado a sua abordagem em data anterior, quando foi encaminhada à Delegacia de Polícia e liberado, tendo sido reconhecido porte de droga para o próprio consumo naquela ocasião. A falsa acusação – alegou que os policiais lhe mostraram bolsa contendo as demais drogas no interior da viatura – decorreu de seus antecedentes criminais.

A negativa de autoria, contudo, ficou isolada nos autos pelo mais da prova colhida em instrução.

Sob o crivo do contraditório, os policiais civis João Batista Alves e Maurício Menezes de Barros, em relato coeso e harmônico com o anterior, informaram os passos da diligência encetada na data dos fatos e espancaram qualquer dúvida acerca da veracidade da hipótese acusatória:

O local é conhecido ponto de tráfico de droga. Na data do fato, dirigiram-se ao local, nas imediações de conjunto habitacional, e visualizaram o acusado portando pochete. Cercaram o local para efetuar a abordagem. Percebendo a presença policial, o réu buscou fuga pelo lado 'debaixo' da via, tendo sido abordado pelo policial João.

A mencionada pochete foi apreendida em poder do agente. Dentro dela havia porções de cocaína, em maior quantidade, e uma ou duas porções de maconha. Também foi apreendida a quantia de R\$14,00 em dinheiro trocado.

Inquirido, após ofertar inicial negativa, o réu admitiu a prática da mercancia ilícita.

ROBERTO NICOLAS suava muito e aparentava estar sob efeito de droga.

O policial Maurício acrescentou que tinha efetuado a abordagem do acusado em data anterior, ocasião na qual foi liberado pela Autoridade Policial por ter sido capitulada a conduta como sendo porte de droga para o próprio consumo.

O policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO - DJU 18.10.1996 - p. 39.846).

Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas (RDTJRJ 7/287).

Os policiais não conheciam o acusado e não tinham razão para narrar dinâmica diversa da verdadeiramente praticada na data do fato.

Salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade da testemunha, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testigos que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à míngua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Inexiste o mínimo indício de que os policiais tivessem qualquer motivo para colocar em risco as suas carreiras forjando uma situação prejudicial ao réu, que sequer conheciam, imputando-lhe falsamente crime.

Nesta linha: "São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (TJSP, rel. Osni Pereira, Apelação Criminal nº 0008782-89.2011.8.26.0590, 16ª Câmara Criminal, julgado em 27/01/2015).

É certo que as testemunhas não recordaram alguns detalhes da diligência, o que é compreensível diante do número de diligências das quais os policiais participam e do lapso temporal decorrido entre o fato e a oitiva em Juízo.

Ainda nessa quadra, cumpre anotar que se as testemunhas são concordantes no essencial, eventual esquecimento ou contradição em pontos secundários não é mal, porque reveste os depoimentos de credibilidade.

Se fossem rigorosamente idênticos, ponto por ponto, passariam de imediato a impressão de que oriundos de uma única fonte, artificialmente composta e até fraudulentamente multiplicada (Rel. CORRÊA DE MORAES - RJTACRIM 33/82). Além da harmônica prova oral acusatória, a variedade e a espécie de substância entorpecente apreendida (01 porção de maconha e 50 porções de cocaína), a forma como acondicionada (individualmente), a apreensão de quantia em dinheiro trocado (R\$14,00), além das circunstâncias da prisão, tornam evidente que a droga se destinava ao consumo de terceiro.

Tais circunstâncias constituem elementos relevantes para a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, conforme preconiza o artigo 28, §2º, do citado Diploma.

Consigne-se que, embora o réu não tenha sido preso enquanto efetuava a venda da droga apreendida, tal circunstância, por si só, não afasta a imputação feita na denúncia.

Isso porque o crime de tráfico, como delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, consuma-se com a ocorrência de qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, dentre as quais se insere aquela imputada ao acusado na denúncia, sendo suficiente a identificação da finalidade mercantil.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico de droga pelo réu.

Não militam quaisquer excludentes de ilicitude ou dirimentes em benefício do acusado, ausente prova nesse sentido.

Não se olvida que ROBERTO NICOLAS se declarou usuário de droga.

Ainda que adotada como verdadeira (os policiais confirmaram que o agente estava sob efeito de droga), a premissa não tem o condão de afastar a culpabilidade do réu.

Em Juízo, o acusado não apresentou qualquer indicativo que revelasse estar sua capacidade cognitiva comprometida em razão do uso de entorpecentes. Pelo contrário, revelou-se lúcido e eloquente, relatando sua versão dos fatos de forma concatenada e segura, negando a prática do delito.

Fato é que, preso desde janeiro de 2022, inexistiu nos autos relato de alteração comportamental ou de saúde típica de quadro de dependência química. O acusado não se declarou dependente químico, não há pedido defensivo para instauração do incidente de dependência químico-toxicológica e o Juízo não vislumbrou elementos para a sua determinação de ofício.

Conforme preceitua o art. 28, II, do CP, a embriaguez, voluntária ou culposa, ausente prova em sentido contrário, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.

No referido dispositivo legal, o Estatuto Repressivo adotou a teoria da *actio libera in causa*, "segundo a qual, considera-se imputável quem se põe em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, seja dolosa ou culposamente, e nessa situação comete o crime" (TJMG, AC1.0352.03.007518-3/001, Rel. Desª MARIA CELESTE PORTO, DJ 24/2/2007).

Ainda nessa quadra, saliente-se que a condição de usuário não afasta, necessariamente, a de traficante. É sabido que, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra.

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

"A condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da droga. Não descaracteriza o delito de tráfico de substância

entorpecente o fato de a Polícia haver apreendido pequena quantidade do tóxico em poder do réu" (STF 1ª T. HC n. 74.420-6/RJ Rel. Min. Celso de Mello DJU de 19.12.96, p. 51.768).

Portanto, o acusado realizou conduta típica, antijurídica (art. 33, caput, a Lei nº 11.343/06) e, em face de sua culpabilidade, impõem-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que não militam quaisquer justificativas ou dirimentes. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente desfavoráveis ao acusado. Não se sobressai, no fato em tela, maior grau de censurabilidade da conduta do agente, inerente ao tipo penal em espécie. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (autos nº 0017456-61.2016.8.26.0564 – por crime de roubo majorado. Tramitou na 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 28/03/2017. Cumpria pena em regime aberto desde 28/03/2019, cf. certidão criminal às págs.31/33 e F.A às págs.34/37), elevo a reprimenda do acusado em 1/6, o que perfaz 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Não há atenuantes na espécie.

Não incidem causas de aumento de pena. Não se aplica a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, não preenchidos os predicados legais. O RÉU É REINCENTE.

O valor de cada dia-multa será calculado no valor unitário mínimo e atualizado desde a data da infração.

O regime para o início de cumprimento de pena é o fechado.

Mostra-se adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a gravidade CONCRETA do delito de tráfico, circunstâncias em que foi praticado e suas consequências (crime de perigo abstrato), que demonstram a periculosidade e ousadia do agente, aptas a reclamar reação severa, proporcional e seguramente eficaz, sob pena de impunidade.

Inexiste relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e o regime prisional, que deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

O acusado é reincidente (recente condenação anterior e definitiva pelo crime de roubo). Em breve espaço de tempo voltou a delinquir, o que demonstra que faz do crime o seu meio de vida, não se tratando, o fato em tela, de mero descuido na vida de ROBERTO NICOLAS.

Nesse passo, regime mais benéfico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou aplicação do "sursis", a par de não preenchidos os requisitos subjetivos dos artigos 33, §3º, 44 e 77, ambos do Código Penal, descaracterizaria a eficácia intimidante da pena e constituiria incentivo à reiteração da conduta.

Resultaria ilógica, nesta situação, a aplicação de tais benesses, sob pena de esvaziar-se o tratamento rígido que a Lei buscou propiciar a fim de concretizar a política criminal voltada a dirimir a traficância de entorpecentes (afastado o tráfico privilegiado), que, a propósito, envolve sempre outras práticas delitivas execráveis que tanto devastam o país.

Não se olvida que a Lei nº 12.736/12 incluiu o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, para permitir que o Juiz desconte na sentença o tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação no total de pena imposta, o que se dá unicamente para fins de fixação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Ocorre que referida alteração apenas tem razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência, o que não se vê patenteado no caso em tela.

Ainda que se entenda que o tempo de prisão processual deva ser descontado para a aplicação do artigo 33, §2º, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em razão do quantum, mas pelas desfavoráveis condições subjetivas apresentadas pelo acusado, que tornam mais reprovável a conduta criminosa, com base no artigo

33, §3º, do Código Penal.

Há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a modalidade mais gravosa.

Acerca do assunto, merece destaque o seguinte julgado emanado do E. TJSP, que já teve a oportunidade de se manifestar sobre a detração: "É inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Deve o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria" (TJSP - 5ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 - Rel. Des. Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.).

Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão no Juízo da Execução.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar o acusado ROBERTO NICOLAS DE SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelas razões expostas alhures.

O réu respondeu ao processo preso (convertida a prisão em flagrante em preventiva - págs.38/41).

Em que pese a excepcionalidade da custódia cautelar, a medida ainda é necessária para o atendimento da finalidade da persecução penal.

Presente o fumus comissi delicti, consubstanciado nas declarações dos policiais civis e na presente condenação. O periculum libertatis evidencia-se não apenas pela gravidade CONCRETA da conduta imputada ao acusado, mas pelas desfavoráveis condições subjetivas que apresenta, a demonstrar a ineficácia das medidas cautelares para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Não se trata de presunção genérica de periculosidade de indivíduo assim acusado. Cuida-se de constatação cotidiana, reforçada pelo legislador pátrio: O tráfico de drogas é atividade que denota a criminalidade organizada; a disseminação das drogas impõe aos usuários a prática de delitos antecedentes, contra o patrimônio alheio, para sua aquisição, e de delitos posteriores, geralmente contra pessoas, em razão da alteração do estado psíquico decorrente de seu consumo.

O acusado é reincidente. A F.A e certidão criminal juntadas aos autos apontam que ainda cumpria pena definitiva anterior, embora fora de estabelecimento prisional, quando foi preso em flagrante pelo fato em apreço.

Não há dúvida de que adota a prática delitiva como meio de vida. Há fortes indícios de que, em liberdade, voltará a delinquir.

Não se cuida, na espécie, de apenas um desvio na vida do réu, que assim ostenta periculosidade acentuada e diferenciada, bem como conduta social avessas aos preceitos que presidem a convivência em comunidade.

As medidas cautelares previstas na legislação processual penal não se mostram, portanto, adequadas e suficientes para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo imprescindível para eficácia da persecução penal a manutenção da custódia cautelar.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o réu não poderá apelar em liberdade. Expeça-se o necessário e recomende-se o acusado na prisão onde se encontra recolhido.

Em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva

será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ. Inexiste prejuízo aos sentenciados quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019) e não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência. Considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar nesta sentença, há inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019).

Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido, oriundo do tráfico de droga, em favor da União.

De plano:

- a) não tendo havido controvérsia sobre a natureza ou quantidade da substância ou do produto, bem como sobre a regularidade do respectivo laudo químico-toxicológico, oficie-se à Autoridade Policial para destruição das substâncias entorpecentes apreendidas nos autos;
- b) autorizo a destruição da bolsa usada para acondicionar a droga apreendida nos autos. Oficie-se.

Oportunamente, comunique-se Distribuidor e IIRGD.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

- a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se guia de recolhimento definitiva;
- b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República;
- c) Calcule-se a multa, intimando-se, em seguida, o réu para que proceda ao pagamento;
- d) Providencie-se a transferência do numerário depositado nos autos (pág.43) para a conta do FUNAD, nos termos do artigo 481-A, das NSCGJ, e oficie-se à SENAD informando sobre a decretação do perdimento da quantia apreendida e o local do depósito.

Custas pelo réu no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03. A exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C

São Bernardo do Campo, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA